

1500232-50.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como parte do entorpecente apreendido estava embalado, características típicas do tráfico varejista, além de ter ocorrido a apreensão de faca e prato com resquícios de drogas, indicando que acusado utilizava a residência para fracionar e embalar a droga.

A esse respeito, anoto que o próprio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500232-50.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-50.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE FERNANDES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Filipe Fernandes da Silva foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 09h00min, na Rua Leonilda dos Santos Mariano nº 76, Jardim Pansani - Santa Teresinha, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 171 (cento e setenta e uma) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 542,8g (quinhentos e quarenta e dois gramas e oito decigramas), e 01 (um) tijolo de cocaína em forma de "crack", com peso bruto aproximado de 280,3g (duzentos e oitenta gramas e três decigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 113/115) e a denúncia foi recebida aos 12 de abril de 2022 (fls. 116/117).

Houve citação (fls. 149).

A representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, condenando o acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer, preliminarmente, reconhecimento de nulidade da apreensão realizada por reputa indevido o ingresso dos guardas civis na residência do acusado, assim como sustenta que os guardas civis não tinham atribuição para a ação. No mérito, no caso de condenação, requer benesses quanto à pena a ser imposta.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 10); pelo laudo pericial do local (fls. 67/71); pelos laudos periciais toxicológicos (fls. 91/83, 84/86; 87/89 e 90/92) e por toda a prova oral colhida em juízo.

A guarda municipal Gisele Aparecida de Godoi disse que estava em patrulhamento pelo bairro e notou indivíduo carregando uma mochila saindo de um imóvel. Ele notou a viatura e retornou para o interior da casa. A guarnição conversou com uma mulher, que se identificou como irmã do acusado, autorizou a entrada e afirmou que o que “a equipe queria estava no quarto”. Ingressou no local e localizou porções de maconha, além de um prato, em cima da mesa de cabeceira, uma porção de crack com duzentos e oitenta gramas. Não conhecia o acusado e desconhecia denúncias indicando o envolvimento do acusado com tráfico de drogas.

O guarda municipal Lucas Fernando da Silva prestou depoimento no mesmo sentido, confirmando a apreensão de faca sobre um prato, que seria utilizado para fracionamento do crack, bem como a apreensão de porções de maconha já fracionadas. Maria Laura Muroní da Silva, irmã do acusado, disse que estava no interior de sua casa e ouviu barulho, notando que guardas civis tentavam abrir o portão do imóvel. Disse que seu marido foi rendido, mas não identificado pelos servidores, que entraram na casa. Não sabia o teor do documento que assinou na ocasião. Disse que seu irmão não é usuário de drogas. Nega que o acusado tenha saído da casa portando uma mochila, mas confirma que os guardas civis apreenderam a mochila no interior do imóvel. Os guardas civis saíram da casa com uma mochila, mas não viu o conteúdo. Bruna Letícia de Souza, amiga do acusado, disse que a irmã dele assinou um documento sem saber o teor e não autorizou o ingresso dos guardas civis no local. Esclareceu que quando chegou ao local, os guardas civis já estavam no imóvel e o acusado já havia sido removido dali.

Maycon Filipe Cardoso de Almeida disse que estava na sala em companhia da irmã do acusado. Ouviu barulho e verificou que eram os guardas civis. Foi rendido e eles indagaram do “rapaz que estava ali fora”. Indicou que o acusado estava no interior da casa e os servidores entraram no imóvel. Disse que o acusado “saiu, olhou para fora e retornou para dentro”.

Em solo policial, o acusado Filipe Fernandes da Silva disse que estava na posse da droga apreendida, informando que a mesma é de uma terceira pessoa, cujo nome não pode informar, porque teme por sua integridade física e pela integridade física de seus familiares. Disse que estava em seu quarto, com a droga apreendida, quando os policiais lá apareceram (fls. 07).

Em juízo, o acusado disse que os fatos são verdadeiros. Saiu para fumar, entrou novamente na casa e, vinte minutos depois, foi abordado pelos guardas civis em seu quarto. Confirma que guardava as drogas em sua casa. Disse que entrou em contato com pessoa desconhecida, que lhe emprestou dois mil reais. Como não conseguiu honrar a dívida, passou a ser ameaçado por aquele indivíduo, que lhe obrigou a guardar e embalar as drogas apreendidas, sendo que ele passava pelo local para retirar as porções já embaladas. Estava com as drogas há trinta dias em sua casa e não autorizou o ingresso dos policiais.

Deve ser rechaçada a nulidade decorrente da prisão efetuada pelos guardas civis municipais.

Nesse caso, não apenas os guardas civis, mas qualquer do povo estava autorizado a realizar a prisão em flagrante, pois se trata de hipótese de crime permanente, não havendo que se falar em nulidade da prova colhida.

Nesse sentido, em recente precedente, a Egrégia 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que:

Não se sustenta a tese de nulidade da prova sob argumento de que os guardas civis

não possuem atribuição de polícia judiciária ou de investigação criminal. Com efeito, embora constitucionalmente seja atribuída à polícia civil a função de polícia judiciária e à polícia militar o policiamento ostensivo, as guardas civis municipais, instituídas por leis com permissivo do § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, exercem atividades de policiamento, com dever de manutenção da ordem pública e zelo da segurança dos munícipes. Assim sendo, no exercício de suas funções, os guardas civis metropolitanos que constatarem atividade criminosa têm o dever de realizar a prisão em flagrante, o que, aliás, é facultado a qualquer do povo, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal. Nesse sentido é o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 667.413 SP, Relª Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/06/2021). "Não obstante, a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência. Explico. Esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/4/2018). Saliente-se, ademais, que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo. (...) Ainda, tem-se que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal prevê, como órgão componente do sistema de segurança pública, a Guarda Municipal, verbis: "Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei." Apesar da função constitucional das guardas municipais serem restritas à proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se verifica, in casu, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, tendo em vista que a prisão efetuada foi em flagrante, a qual poderia ser realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, na forma do art. 301, do Código de Processo Penal, verbis: "Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito." Nesse sentido, autorizada estava a prisão em flagrante no caso concreto. Portanto, não há falar, em situações como tais, em inexistência de denúncia anônima, de mandados de prisão, assim como dos de apreensão de material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância. (STJ, Habeas Corpus nº 650.864 SP, Rel. Min. Felix Fischer, Decisão Monocrática, j. 21/05/2021). (Apelação Criminal n. 1501969-26.2020.8.26.0567, Relator Desembargador Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Quanto ao ingresso na residência do acusado, entendo que a medida está em consonância com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616, em que se fixou a possibilidade de realização do varejamento domiciliar forçado pelos agentes públicos, sem mandado judicial, se "amparado em fundadas razões" para tanto, como se colhe da ementa daquele precedente:

Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de

flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. (....) 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

No caso dos autos, mesmo sem a concordância do agente, estavam bem delineadas as fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos em sua residência, pois os guardas civis afirmaram que ele portava uma mochila e, ao avistar a guarnição, retornou para o interior da casa, conduta que chamou a atenção da equipe e, nesse contexto, justificava a abordagem, ainda que no interior da residência. Por fim, ainda a esse respeito, anoto que Maycon Filipe, cunhado do acusado, na presente data, afirmou que ele estava do lado de fora e retornou para o interior da residência, o que está em consonância com a versão apresentada pelos guardas civis municipais.

Se tal não bastasse, os guardas civis informaram, em juízo, sob o crivo do contraditório, que a entrada na casa contou com a anuência da irmã do acusado. É verdade que, na presente data, Maria Laura se retratou e informou ter assinado documento sem realizar a leitura, mas evidentemente tal se deve ao fato de que se trata da irmã do acusado, interessada, portanto, no reconhecimento da nulidade e, consequente soltura do agente.

Quanto ao mérito, entendo que o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como parte do entorpecente apreendido estava embalado, características típicas do tráfico varejista, além de ter ocorrido a apreensão de faca e prato com resquícios de drogas, indicando que acusado utilizava a residência para fracionar e embalar a droga.

A esse respeito, anoto que o próprio acusado confessou que guardava as drogas em sua residência e que chegava a embalar o material em porções fracionadas.

De se anotar que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada e tinha em depósito grande porção de 'crack' para promover o fracionamento, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de

tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes e o increpado confessou a guarda das drogas, inexistindo contradição relevante no depoimento dos servidores públicos que indique seja falso o relato apresentado. Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade acima do patamar mínimo, na medida em que ocorreu a apreensão de drogas diversas e a quantidade apreendida é relevante, justificando, nos termos do artigo 42 da lei n. 11.343/06, o recrudesimento da reprimenda.

Nesse cenário, fixo a pena privativa de liberdade em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, com o retorno da pena ao mínimo legal.

Em terceira fase, incide também a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de fls. 67/71 revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existe campo de futebol, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Assim, majoro sua pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, pois houve a apreensão de balanças, embalagens, faca com resquícios de droga, revelando a incorporação do acusado a grupo dedicado a atividades criminosas. A esse respeito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AVENTADA REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas são agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 3. Concluído pelas instâncias ordinárias, com fulcro nos elementos colhidos na instrução (apreensão de "balança de precisão, prensa, várias cápsulas plásticas tipo eppendorf etc."), que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. (hc 286.336/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, julgado aos 5/4/2016, STJ).

Por estes fundamentos, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, com quem foi apreendida expressiva quantidade de drogas diversas.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Filipe Fernandes da Silva à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Expeça-se certidão de honorários à patrona dativa nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta, que deverá ser revertido ao FUNAD após o trânsito em julgado. Determino, ainda, a destruição dos objetos apreendidos, o que deverá ocorrer independentemente do trânsito em julgado.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 23 de junho de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA